

MAYA BT. AHMAD FUAAD

lwn

HISHAM B. HALIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Datuk Aidi b. Moktar (Pengerusi), YA Dato' Yusof b. Musa (Ahli Panel), YA Tuan Saarani b. Ismail (Ahli Panel), pada 9 Oktober 2017 / 19 Muharram 1439H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0090-2017]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Mohd. Rafie b. Mohd. Shafie dan Mohd. Reza b. Mohd. Rafie dari Tetuan Chambers of Rafie Mohd. Shafie & Associates.

Peguam Syarie Responden : Peguam Syarie Responden : Saadiah bt. Din, Dato' Zainul Rijal b. Abu Bakar dan Mohd. Irwan b. Mubarak dari Tetuan Saadiah, Khoo, Lo & Co.

PERMOHONAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan semakan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut;-

- i. Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan berhubung perintah/keputusan Hakim Bicara bertarikh 9/8/2017 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. 10300-099-0492-2017.
- ii. Mahkamah Yang Mulia ini hendaklah membatalkan serta-merta perintah bertarikh 9/8/2017 Permohonan No. 10300-099-0492-2017 yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Selangor.
- iii. Mahkamah Yang Mulia ini mengekalkan perintah bertarikh 23/2/2017 Permohonan No. 10300-038-0118-2017 dan perintah bertarikh 18/7/2017 Permohonan No. 10300-099-0419-2017 yang telah diputuskan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor
- iv. Apa-apa perintah atau relif lain yang suai manfaat yang difikirkan patut dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

FAKTA KES

[2] Pemohon telah menfailkan tuntutan hak jagaan anak2 orang anak yang bernama Misha bt. Hisham (lahir 4/3/2013) dan Myra bt. Hisham (lahir pada 20/9/2015) terhadap Responden di MTS Shah Alam di dalam kes no. 10300-028-0117-2017 (**kes induk**) pada 22/2/2017. Pada tarikh yang sama juga, Pemohon telah menfailkan satu permohonan perintah interim hak jagaan anak secara ex-parte di dalam kes no. 10300-038-0118-2017. Pada 23/3/2017, YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan Pemohon di dalam kes no. 10300-038-0118-2017

dan memerintahkan hak penjagaan sementara dua orang anak tersebut diberikan kepada Pemohon.

[3] Kes tersebut telah telah ditangguhkan untuk pendengaran secara inter-parte pada 21/3/2017 dan pada tarikh tersebut YA Hakim Bicara telah mengekalkan perintah hak jagaan sementara dua anak tersebut kepada Pemohon dan YA Hakim Bicara juga memerintahkan Responden diberikan hak lawatan dan bermalam pada hari Khamis jam 5.00 petang dan dihantar semula kepada Pemohon pada hari Sabtu jam 5.00 petang.

[4] Pada 3/3/2017, Responden telah memasukkan satu permohonan interlocutori bantahan awal terhadap tuntutan kes induk hak jagaan anak yang difailkan oleh Pemohon yang memohon agar saman dan tuntutan Pemohon di dalam kes tersebut dibatalkan kerana Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tidak mempunyai bidangkuasa untuk membicarakan kes tersebut disebabkan Pemohon bukan pemastautin Negeri Selangor. Permohonan tersebut telah didengar pada 21/3/2017 dan pada 27/7/2017, YA Hakim Bicara telah menolak bantahan awal tersebut dan memutuskan bahawa ia berbidangkuasa untuk membicarakan kes induk hak jagaan anak tersebut. Responden telah tidak berpuashati dengan keputusan itu dan telah menfailkan Notis Rayuan.

[5] Responden telah menfailkan 3 Permohonan Kebenaran Komital terhadap Pemohon, iaitu pada 17/3/2017 (Permohonan no. 10300-075-0174-2017), 12/4/2017 (Permohonan no. 10300-075-0234-2017) dan 7/7/2017 (Permohonan no. 10300-074-0396-2017). Permohonan Responden adalah berkaitan kegagalan/keingkaran Pemohon untuk mematuhi terma perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah pada 23/2/2017 dan 21/3/2017.

[6] Pada 7/7/2017 juga Responden telah menfailkan Permohonan Pindaan Perintah Interim secara ex-parte di dalam kes no. 10300-099-0397-2017 dan pada 13/7/2017 YA Hakim Bicara telah meluluskan permohonan tersebut dan membatalkan perintah hak jagaan sementara bertarikh 21/3/2017 seterusnya memerintahkan hak jagaan sementara dua orang anak tersebut diberikan kepada Responden.

[7] Pemohon pula telah menfailkan Permohonan Penggantungan Perintah secara ex-parte pada 13/7/2017 di dalam kes no. 10300-099-0419-2017 dan pada 18/7/2017, YA Hakim Bicara telah memerintahkan Perintah Mahkamah bertarikh 21/3/2017 di dalam Permohonan no. 10300-038-0118-2017 dan Perintah Mahkamah bertarikh 13/7/2017 di dalam permohonan no. 10300-099-0397-2017 di rafa'kan ke Mahkamah Rayuan Syariah untuk semakan.

[8] Pada 3/8/2017 Responden telah menfailkan Permohonan Interlokutori secara ex-parte di dalam kes no. 10300-099-0492-2017. YA Hakim Bicara telah membuat perintah pada 9/8/2017 bahawa Perintah bertarikh 18/7/2017 di dalam kes no. 10300-099-0419-2017 adalah luput dan terbatal dan bahawa diperintahkan hak jagaan kedua-dua anak tersebut diberikan kepada Responden. Pendengaran secara inter-parte bagi kes tersebut telah ditetapkan pada 29/8/2017.

[9] Pemohon telah menfailkan permohonan semakan ini pada 15/8/2017 atas alasan perintah bertarikh 9/8/2017 di dalam kes no. 10300-099-0492-2017 adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang.

[10] Pada prosiding pendengaran secara inter-parte bertarikh 29/8/2017 bagi kes no. 10300-099-0492-2017, Pemohon telah gagal hadir ke Mahkamah dan YA Hakim Bicara telah membuat perintah seperti berikut;-

- i. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara anak yang bernama Misha bt. Hisham diberikan kepada ibu manakala hak jagaan sementara anak bernama Myra bt. Hisham diberikan kepada bapa.
- ii. Mahkamah memerintahkan hak lawatan bagi kedua-dua anak ini dilakukan pada setiap hari Jumaat (kecuali cuti umum) di Mahkamah Tinggi Syariah Ahah Alam dari jam 9.00 pagi hingga 12 tengahari dengan pengawasan polis atau pegawai Mahkamah.
- iii. Pemohon dan Responden dikehendaki membawa kedua-dua orang anak pada setiap waktu lawatan tersebut.
- iv. Sesi lawatan tersebut hanya melibatkan Pemohon, Responden dan anak-anak sahaja tanpa gangguan ahli keluarga dan peguam kedua-dua pihak.
- v. Jika mana-mana pihak gagal mematuhi perintah ini, maka pihak-pihak tersebut telah melakukan suatu penghinaan dan boleh dikomitkan ke penjara.
- vi. Mahkamah memerintahkan kes permohonan no. 10300-099-0541-2017 terbatal kerana perintah ex-parte bertarikh 9/8/2017 telah terbatal dengan perintah interim ini.
- vii. Perintah interim ini kekal sehingga kes induk hak jagaan Saman no. 10300-028-0117-2017 diputuskan.

[11] Pada 27/8/2017, Responden juga telah menfailkan permohonan semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap perintah Mahkamah bertarikh 29/8/2017 dan permohonan tersebut didaftarkan dengan no. 10000-003-0107-2017. Alasan

Responden adalah YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang, prosedur dan Hukum Syarak apabila membuat perintah bertarikh 29/8/2017.

[12] YA Hakim Bicara juga telah memohon semakan ke Mahkamah Rayuan Syariah pada 2/10/2017 terhadap perintah-perintah yang telah dibuat pada 13/9/2017 di dalam kes-kes no. 10300-075-0174-2017, 10300-075-0234-2017 dan 10300-074-0396-2017 iaitu sama ada prosiding permohonan kebenaran komital perlu diteruskan atau tidak apabila isu bidangkuasa Pemohon dalam kes induk hak jagaan belum diputuskan lagi oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[13] Berdasarkan notis permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas **keputusan/perintah** YAHakim Bicara MTS Selangor di dalam kes no. 10300-099-0492-2017 bertarikh 29/8/2017 yang memutuskan seperti di perenggan [1] penghakiman ini.

[14] Di dalam masa yang sama, terdapat juga satu permohonan semakan yang telah difailkan oleh Responden iaitu kes no. 10000-003-0107-2017 dan 3 permohonan semakan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara iaitu kes no. 10100-003-0108-2017, 10000-003-0109-2017 dan 10000-003-0110-2017. Kesemua permohonan semakan ini adalah berkaitan dengan perintah MTS Selangor bertarikh 29/8/2017 dan juga kes induk hak jagaan anak no. 10300-028-0117-2017. Oleh yang demikian, kami akan meneliti dan mengambilkira semua permohonan-permohonan semakan tersebut di dalam penghakiman ini.

[15] Sesuatu permohonan semakan yang dikemukakan ke Mahkamah Rayuan Syariah adalah dibuat berdasarkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut sesuai atau tidak untuk dibuat proses semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – **Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah** telah menggariskan panduan bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak. Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

[16] Berdasarkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, skop kepada sesuatu permohonan semakan adalah dua perkara iaitu; (1) apa-apa perkara, dan (2) prosiding. Perkataan ‘prosiding’ adalah jelas maksudnya iaitu prosiding yang dijalankan oleh MTS. Manakala perkataan ‘apa-apa perkara’ telah ditafsirkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Sa’diah bt. Hj. Tamin lawan Zainal Arsyad b. Mohd. Amin* [2015] JH41(2) 192 sebagai apa-apa perkara termasuklah juga keputusan/penghakiman/perintah MTS. Manakala maksud ‘pada mana-mana peringkat’ juga memberi maksud kes yang selesai diputuskan juga boleh disemak. Berikut adalah seksyen 68 tersebut;

- (1) *Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika didapati perlu olehnya demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang*

berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[17] Manakala panduan yang diberikan di dalam AA 7/2014 adalah selari dengan penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012)* di mana Panel Rayuan menyatakan ;

“ Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

ii. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

iii. *Jika kes belum diputuskan, isu yang berbangkit adalah berkaitan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*

iv. *Sesuatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana di dalam perenggan (ii).*

v. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*

vi. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan."*

[18] Berdasarkan Notis Permohonan dan Afidavit yang diikrarkan oleh Pemohon bertarikh 15/8/2017, antara alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah bahawa perintah YA Hakim Bicara pada 9/8/2017;-

- a. Adalah bercanggah dengan peruntukan undang-undang kerana membenarkan Responden menfailkan kes secara ex-parte. Menurut

Pemohon, oleh kerana Pemohon adalah Plaintiff di dalam kes induk hak jagaan, maka hanya Pemohon sahaja yang berhak untuk menfailkan permohonan secara ex-parte manakala apa-apa permohonan yang dibuat oleh Responden hendaklah dibuat secara inter-parte.

- b. Adalah keterlaluan dan melangkaui kuasa dengan memerintahkan Polis Diraja Malaysia memecah masuk mana-mana rumah untuk mengambil anak tersebut dan menahan mana-mana orang yang gagal memberi kerjasama untuk perlaksanaan perintah tersebut.

[19] Responden pula di dalam permohonan semakannya no. 10000-003-0107-2017 menyatakan bahawa permohonan tersebut dibuat berdasarkan alasan-alasan antaranya YA Hakim Bicara dalam memberikan perintah bertarikh 29/8/2017 telah tersilap dari segi prosedur dan tersalah arah dari segi teknikal kerana tidak mengikut Arahan Amalan No. 5 Tahun 2016 – Garis Panduan Prosiding Ex-Parte Hadhanah dan Injunksi. YA Hakim Bicara juga telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak apabila membatalkan permohonan Responden di dalam kes tersebut tanpa terlebih dahulu mendengar merit permohonannya.

[20] Berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan Responden tersebut, kami berpendapat kedua-dua pihak telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan-permohonan tersebut mempunyai asas dan merit untuk kami membuat proses semakan kerana ianya melibatkan kesilapan undang-undang dan hukum syarak serta kekhilafan prosedur dan tatacara.

[21] Setelah kami meneliti kedua-dua permohonan semakan yang dikemukakan oleh Pemohon (kes no. 10000-003-0090-2017) dan juga Responden (kes no.10000-

003-0107-2017), kami mendapati wujudnya beberapa kes yang telah difailkan oleh pihak-pihak dan beberapa perintah yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara setelah kes induk hak jagaan anak difailkan oleh Pemohon pada 22/2/2017. Semua kes-kes tersebut sama ada secara ex-parte atau inter-parte merupakan kes-kes interlokutori berkaitan perintah interim hak jagaan anak. Kami merasa amat terkilan apabila maklumat yang kami minta dan perolehi daripada Ketua Pendaftar Mahkamah Rayuan Syariah menunjukkan bahawa terdapat 14 kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan 9 kes di Mahkamah Rayuan Syariah yang telah difailkan oleh kedua-dua pihak selepas kes induk hak jagaan anak difailkan. Kes-kes tersebut yang berjumlah 23 kes adalah ;-

Mahkamah Tinggi Syariah

- i. 10300-038-0118-2017
- ii. 10300-041-0141-2017
- iii. 10300-075-0174-2017
- iv. 10300-075-0234-2017
- v. 10300-099-0287-2017
- vi. 10300-041-0299-2017
- vii. 10300-074-0339-2017
- viii. 10300-074-0396-2017
- ix. 10300-099-0397-2017
- x. 10300-074-0398-2017
- xi. 10300-099-0419-2017
- xii. 10300-099-0492-2017
- xiii. 10300-099-0541-2017
- xiv. 10300-074-0545-2017

Mahkamah Rayuan Syariah

- xv. 10000-099-0080-2017
- xvi. 10000-041-0080-2017
- xvii. 10000-003-0090-2017
- xviii. 10000-003-0093-2017
- xix. 10000-099-0100-2017
- xx. 10000-003-0107-2017
- xxi. 10000-003-0108-2017
- xxii. 10000-003-0109-2017
- xxiii. 10000-003-0110-2017

[22] Kami juga mendapati bahawa beberapa perintah interim telah dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara yang kemudiannya ada yang dibatalkan, di gantung dan diubah akibat daripada permohonan-permohonan yang difailkan oleh kedua-dua pihak selepas kes hak jagaan induk difailkan.

[23] Berdasarkan afidavit-afidavit kedua-dua pihak yang difailkan di dalam kedua-dua permohonan semakan tersebut, pada hemat kami pertikaian yang berlaku diantara Pemohon dan Responden di dalam kes hak jagaan anak ini telah mencapai ke suatu tahap yang sudah tidak terkawal dan dibimbangi mendatangkan kemudaratan kepada anak-anak yang menjadi subjek pertikaian. Kami mendapati telah wujudnya aduan dan dakwaan berkaitan kegagalan memberikan hak anak-anak untuk berjumpa dengan ibu atau bapa dan lebih serius lagi adanya aduan dan dakwaan berkenaan pencabulan dan penderaan terhadap anak-anak.

[24] Mahkamah Rayuan Syariah merupakan Mahkamah yang berada di hirarki yang paling tinggi dan mempunyai kuasa-kuasa tertentu sebagaimana yang diberikan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Berdasarkan seksyen 68(1) Enakmen tersebut, Mahkamah ini boleh atas kehendaknya sendiri atas kepentingan keadilan melakukan pengawasan dan penyemakan terhadap apa-apa prosiding dan perintah di dalam Mahkamah Tinggi Syariah dengan mengambil atau memeriksa mana-mana rekod dan mengeluarkan apa-apa arahan.

[25] Kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah boleh diaplikasikan pada mana-mana peringkat dan prosiding jika difikirkan perlu oleh Mahkamah untuk berbuat demikian demi keadilan. Di dalam kes *Mohd. Ibrahim b. Mohd. Sharif lawan Pendakwa Syarie Pulau Pinang [1999] JH13(2) 203*, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Pulau Pinang telah menggunakan kuasa pengawasan dan penyemakan ini ketika memutuskan rayuan Perayu berdasarkan seksyen 55 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam (Pulau Pinang) 1993. Peruntukan seksyen 55 ini adalah sama dengan peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003. YA Datuk Abdul Hamid b. Mohamed (sekarang Tun) didalam penghakimannya menyatakan;-

“perlu ditekankan bahawa seorang tertuduh yang mengaku salah tidak berhak untuk merayu terhadap sabitan. Tetapi Mahkamah berhak untuk meneliti rekod rayuan dan di mana patut dilakukan kerana terdapat kegagalan keadilan, mengenyepikan sabitan berkenaan. Ini hak Mahkamah Rayuan, bukan hak Perayu(tertuduh) dan Mahkamah Rayuan melakukannya dengan memakai kuasa penyemakan “

[26] Manakala di dalam kes *Wahid b. Abdul Shattar lawan Rosidah bt. Ahmad (kes no. 10000-099-0008-2016 – belum dilaporkan)* Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam penghakimannya pada 9/6/2016 semasa mengulas mengenai pemakaian kuasa pengawasan dan penyemakan berdasarkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003 telah menyatakan;-

“ Apabila peruntukan itu menyebut boleh menyemak pada mana-mana peringkat ia memberi maksud Mahkamah Rayuan Syariah boleh di atas kehendaknya memanggil mana-mana rekod perbicaraan mana-mana Mahkamah di bawahnya samada kes yang telah selesai diputuskan atau sedang di dalam prosiding untuk tujuan penyemakan. Tafsiran ini selaras dengan Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014..... ”

[27] Pada hemat kami, oleh kerana hal keadaan pertikaian yang berlaku diantara Pemohon dan Responden adalah sedemikian rupa, maka adalah perlu untuk kami campurtangan serta merta di dalam perintah yang telah dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan hak jagaan sementara anak-anak tersebut. Dengan itu, kami bukan sahaja akan membuat semakan terhadap perintah yang telah dibuat oleh YA Hakim Bicara di dalam kes no. 10300-099-0492-2017, bahkan kami akan memanggil dan memeriksa kesemua 14 rekod kes yang berkaitan dengan kes induk hak jagaan anak yang telah difailkan oleh Pemohon di Mahkamah Tingi Syariah.

[28] Kami menggabungkan keseluruhan kes-kes tersebut di dalam satu penghakiman ini kerana ianya melibatkan pihak-pihak yang sama serta melibatkan fakta dan isu yang berkaitan antara satu sama lain.

[29] Pada 22/2/2017, Pemohon telah menfailkan 2 kes iaitu tuntutan kes induk hak jagaan anak dan juga permohonan perintah interim hak jagaan anak secara ex-parte. Kami telah memanggil dan memeriksa kedua-dua rekod kes ini iaitu rekod kes no.10300-028-0117-2017 dan 10300-038-0118-2017. Bagi kes induk hak jagaan, kami mendapati bahawa proses sulh telahpun gagal dan prosiding diteruskan untuk Responden menfailkan Penyata Pembelaan. Sehingga ke tarikh semakan ini dibuat, Responden belum memasukkan Penyata Pembelaan.

[30] Manakala bagi rekod kes permohonan perintah interim secara ex-parte kes no. 10300-038-0118-2017, pendengaran telah dibuat pada tarikh 23/2/2017 dan YA Hakim Bicara telah mengeluarkan perintah bahawa hak jagaan kedua-dua anak tersebut diserahkan kepada Pemohon. Kes tersebut telah ditangguhkan pada 21/3/2017 untuk pendengaran secara inter-parte.

[31] Responden telah menfailkan permohonan interlokutori bantahan awal berkaitan bidangkuasa mahkamah terhadap tuntutan kes induk hak jagaan anak dan juga terhadap permohonan perintah interim ex-parte 3/3/2017. Kes permohonan bantahan awal ini telah ditetapkan pendengarannya pada 21/3/2017 iaitu pada tarikh yang sama dengan pendengaran kes perintah interim secara inter-parte. Persoalannya di sini, adakah Mahkamah boleh meneruskan pendengaran bagi kes perintah interim secara inter-parte sedangkan pada tarikh tersebut telah ditimbulkan berkenaan isu berkaitan bidangkuasa Mahkamah bagi kes induk hak jagaan dan juga kes perintah interim?

[32] Pada hemat kami, isu persoalan bidangkuasa Mahkamah yang dibangkitkan di dalam kes bantahan awal hendaklah didengar dan diputuskan terlebih dahulu kerana ianya akan memberikan kesan yang material ke atas prosiding dan perintah yang dibuat. Apa-apa prosiding yang berkaitan sepatutnya hendaklah digantung dan ditangguhkan dahulu. Kami mendapati YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meneruskan prosiding permohonan perintah interim dan telah membuat perintah secara inter-parte pada 21/3/2017.

[33] Keputusan kes bantahan awal tersebut telah diberikan pada 27/7/2007. Responden telah tidak berpuashati dengan keputusan bantahan awal tersebut dan telah menfailkan Notis Rayuan pada 28/7/2017. Kami telah memanggil dan memeriksa rekod kes tersebut iaitu permohonan no. 10300-041-0141-2017 dan mendapati semua prosiding dan prosedur telah dibuat dengan teratur. Perintah YA Hakim Bicara juga telah dibuat setelah segala dokumen dan hujahan difailkan. YA Hakim Bicara juga telahpun menyediakan Alasan Penghakimannya berkaitan kes tersebut.

[34] Oleh kerana keputusan bantahan awal berkaitan bidangkuasa mahkamah tersebut telah dirayu, maka adalah perlu semua prosiding kes induk hak jagaan anak dan juga kes perintah interim digantung dahulu pendengarannya sehingga rayuan berkaitan bantahan tersebut diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Apa-apa tindakan berkaitan prosiding kedua-dua kes tersebut hanya boleh dibuat setelah isu berkaitan bidangkuasa mahkamah dalam kes tersebut diputuskan dan dimuktamadkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah.

[35] Kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila meneruskan prosiding kes perintah interim sedangkan isu bidangkuasa belum lagi

diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Oleh yang demikian, perintah yang dibuat di dalam kes tersebut adalah tidak sah dan terbatal.

[36] Sesuatu permohonan perintah interim hadhanah secara ex-parte hanya boleh dibuat oleh Plaintiff di dalam kes induk berdasarkan sub-seksyen 201(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003. Di dalam kes ini, hanya Pemohon yang mempunyai hak eksklusif untuk menfailkan permohonan perintah interim hak jagaan secara ex-parte. Sekiranya Resonden berhasrat untuk menfailkan apa-apa permohonan berkaitan perintah interim hak jagaan, permohonan berkenaan hendaklah dibuat secara inter-parte. Berikut adalah sub-seksyen 201(3) tersebut;-

(3) Jika pemohon ialah plaintiff dan kes itu satu kes yang mendesak, permohonan itu boleh dibuat secara ex parte yang hendaklah disokong dengan affidavit

[37] Semakan kami kepada beberapa kes yang difailkan oleh Responden mendapati bahawa permohonan tersebut telah dibuat secara ex-parte antaranya kes no. 10300-099-0397-2017 dan 10300-099-0492-2017. Kes-kes tersebut telah didengar dan diputuskan oleh YA Hakim Bicara. Dengan hormatnya kami berpendapat bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila mendengar dan memutuskan permohonan-permohonan tersebut secara ex-parte. Dengan itu, apa-apa perintah yang dibuat di dalam permohonan tersebut adalah tidak sah dan terbatal.

[38] Sesuatu permohonan semakan yang dibuat di Mahkamah Rayuan Syariah akan menyebabkan semua prosiding kes berkenaan di Mahkamah Tinggi Syariah

akan digantung sementara secara automatik berdasarkan sub-seksyen 68(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003. Kami telah mengulas di perenggan 16 penghakiman ini bahawa sesuatu semakan boleh dibuat terhadap ‘prosiding’ dan ‘apa-apa perkara’ yang termasuk di dalamnya keputusan/penghakiman/perintah Mahkamah (**kes Sa’diah bt. Hj. Tamin lawan Zainal Arsyad b. Mohd. Amin –supra**) . Oleh yang demikian, apabila sesuatu permohonan semakan dibuat ke Mahkamah Rayuan Syariah, maka semua prosiding termasuklah semua keputusan/perintah/penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah yang menjadi subjek semakan hendaklah digantung sementara sehingga apa-apa keputusan/arahan dikeluarkan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Berikut adalah sub-seksyen 68(2) tersebut;-

(2) Apabila Mahkamah Rayuan Syariah memanggil rekod tentang apa-apa perkara atau prosiding di bawah subseksyen (1), semua prosiding dalam Mahkamah Tinggi Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Rayuan Syariah.

[39] Kes induk hak jagaan anak yang difailkan oleh Pemohon masih lagi diperingkat pra-perbicaraan di mana Penyata Pembelaan Responden belum lagi dimasukkan. Prosiding ini akan tertangguh lantaran Responden telah memasukkan Notis Rayuan terhadap keputusan bantahan awal yang melibatkan isu bidangkuasa yang perlu diputuskan terlebih dahulu. Rayuan yang difailkan oleh Responden tersebut sudah tentu akan mengambil sedikit masa untuk diputuskan.

[40] Kami mengambil maklum bahawa hal keadaan pertikaian antara Pemohon dan Responden berkaitan perintah interim hak jagaan anak ini adalah sedemikian

rupa sehingga boleh mendatangkan kemudharatan kepada kebajikan anak-anak sebagaimana telah kami ulas di perenggan 23 & 27 penghakiman ini. Dengan kuasa sedia ada yang diberikan oleh seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam(Selangor) 2003, Kami dengan ini akan menggunakan kuasa semakan tersebut untuk meneliti dan menyemak rekod kes permohonan bantahan awal yang difailkan oleh Responden di dalam kes no. 10300-041-0141-2017 walaupun keputusan tersebut telahpun dirayu.

[41] Berdasarkan penelitian dan semakan kami terhadap rekod kes tersebut, kami mendapati bahawa tatacara prosiding yang dibuat dihadapan YA Hakim Bicara adalah betul dan teratur. Kedua-dua pihak telah diberikan peluang untuk menfailkan affidavit dan hujahan masing-masing sebelum keputusan dibuat. Namun adakah perintah/keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara yang menolak bantahan awal Responden itu adalah betul dari segi Hukum Syarak dan Undang-undang?

[42] Alasan bantahan awal Responden di dalam kes tersebut adalah, semasa kes induk hak jagaan dan kes permohonan perintah interim hak jagaan difailkan, Pemohon bukanlah pemastautin Negeri Selangor kerana Pemohon tinggal di Wilayah Persekutuan iaitu di 16-B-1, Hampshire Park Apartment, Persiaran Hampshire 6-8 50450 Kuala Lumpur. Pemohon pula di dalam affidavitnya menyatakan Pemohon adalah berada di dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah Negeri Selangor berdasarkan alamat di dalam kad pengenالannya dan alamat di dalam mykid kedua-dua anaknya adalah di No. 40 Jalan TR9/2, Tropicana Golf & Country Resort 47410 Petaling Jaya. Bahkan Pemohon menyatakan bahawa kad pengenalan Responden juga beralamat di dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah

Negeri Selangor iaitu di 16172, Jln. Dato' Mohd. Sidin, Taman Alam Shah 41000 Klang.

[43] Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara yang mana Mahkamah berpuashati bahawa alamat Pemohon di dalam kad pengenalnya, alamat di dalam sijil nikahnya dan alamat di dalam kedua-dua mykid anaknya adalah di dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Di dalam hal ini, kami merujuk kepada beberapa kes terkini yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan pemakaian seksyen 4 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam antaranya kes *Abdollah Nagash Souratgar lawan Lee Jen Fair (Kes No. 14000-028-0046-2011)* dan kes *Isfanizal b. Iskandar lwn. Norfaezy bt. Yahya & Seorang Lagi [2015] JH42(1) 106*.

[44] Kami bersetuju dengan alasan YA Hakim Bicara bahawa Pemohon beralamat di dalam bidangkuasa Mahkamah Syariah Negeri Selangor berdasarkan kad pengenalan, sijil nikah dan mykid anak-anaknya. Responden sama sekali tidak dapat menyangkal melalui affidavit dan hujahannya bahawa Pemohon tidak layak untuk menfaillkan tuntutan/permohonannya di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara di dalam kes bantahan awal tersebut adalah betul mengikut Hukum Syarak dan Undang-undang di mana Pemohon telahpun memenuhi kehendak seksyen 4 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Selangor) 2003 seperti berikut:-

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam

Negeri Selangor dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri Selangor tetapi tinggal di luar Negeri

[45] Kami sekali lagi ingin menegaskan bahawa campurtangan kami di dalam perintah YA Hakim Bicara adalah perlu demi keadilan dan kebajikan terutamanya kepada kedua-dua anak Pemohon dan Responden yang akan menerima kesan langsung akibat daripada pertikaian ibu bapa mereka. Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa hak anak-anak adalah lebih utama daripada hak Pemohon dan Responden di dalam kes ini. Tambahan pula, hak hadhanah dan hak perwalian yang diperuntukkan dalam Hukum Syarak dan Undang-undang Keluarga Islam bermatlamatkan satu tujuan, iaitu menjaga kemaslahatan dan kebajikan kanak-kanak

[46] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami dengan ini akan mengeluarkan arahan-arahan tertentu bagi memastikan perjalanan kes hak jagaan anak yang difailkan oleh Pemohon akan berjalan dengan lancar demi kebajikan anak-anak dan keadilan kepada kedua-dua pihak sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surah an-Nisaa', ayat 58;-

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا﴾

Terjemahan: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan

apabila kamu menjalankan hukum atas manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adilnya. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon dan juga Responden, DAN setelah kami meneliti permohonan semakan oleh YA Hakim Bicara, DAN setelah Kami memeriksa semua rekod kes-kes yang berkaitan dengan Pemohon dan Responden, maka KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN:-

1. Semua perintah yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah melalui permohonan-permohonan yang berkaitan dengan kes induk hak jagaan anak no. 10300-028-0117-2017 adalah DIBATALKAN.
2. Semua permohonan yang berkaitan dengan kes induk hak jagaan anak no. 10300-028-0117-2017 yang difailkan selepas tarikh 22/2/2017 adalah DIBATALKAN.
3. Mahkamah memerintahkan bahawa Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor mempunyai bidangkuasa untuk mendengar tuntutan hak jagaan anak yang difailkan Pemohon di dalam kes no.10300-028-0117-2017.
4. Mahkamah memerintahkan kes tersebut hendaklah diteruskan prosidingnya dan didengar oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain dengan kadar segera.
5. Mahkamah dengan ini memerintahkan **secara sementara** seperti berikut;-
 - i. Hak Jagaan anak yang bernama Misha bt. Hisham diberikan kepada Pemohon manakala hak jagaan sementara anak bernama Myra bt. Hisham diberikan kepada Responden.
 - ii. Hak lawatan bagi kedua-dua anak ini dilakukan pada setiap hari Selasa dan Jumaat (kecuali cuti umum) di Mahkamah Tinggi

Syariah Ahah Alam dari jam 9.00 pagi hingga 12 tengahari dengan pengawasan polis atau pegawai Mahkamah.

- iii. Pemohon dan Responden dikehendaki membawa kedua-dua orang anak pada setiap waktu lawatan tersebut.
- iv. Sesi lawatan tersebut hanya melibatkan Pemohon, Responden dan anak-anak sahaja tanpa gangguan ahli keluarga dan peguam kedua-dua pihak.

6. Perintah-perintah ini berkuatkuasa serta merta sehingga tuntutan kes induk hak jagaan anak No.10300-028-0117-2017 didengar dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah.

Di baca dan ditandatangani oleh:-

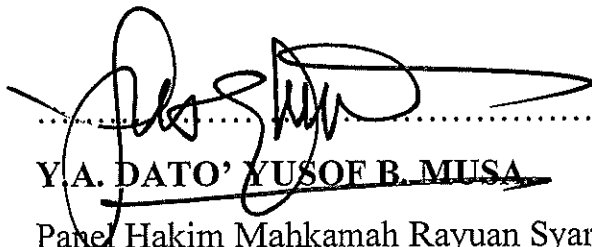


1. **Y.A.A DATUK AIDI B. MOKTAR**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

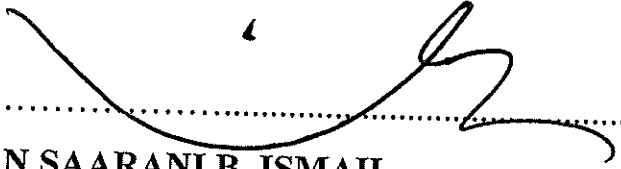
Dipersetujui oleh:-



2. **Y.A. DATO' YUSOF B. MUSA**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **Y.A TUAN SAARANI B. ISMAIL**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

